

1500146-28.2022.8.26.0573

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... de que denúncias anônimas, antecedentes no tráfico, e fuga do suspeito ao perceber a aproximação da viatura não são suficientes para o ingresso no domicílio.

Vejamos:

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

1ª Vara

Rua Ettore Targa, s/nº, São Manuel - SP - cep 18650-000

1500146-28.2022.8.26.0573 - lauda

TERMO DE CONCLUSÃO

São Manuel, 22 de novembro de 2022.

O Escr.,

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500146-28.2022.8.26.0573

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

ANTONIA FAVERO

Juiz de Direito: Dr. JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Vistos.

ANTÔNIA FAVERO foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 06 de maio de 2022, por volta das 11h30minh, na Rua José Maria Santarém, n. 22, Vila Ipiranga, nesta cidade e Comarca de São Manuel, a ré guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 03 (três) tijolos de maconha, com peso líquido de 2.969,79 gramas, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) faca e 01 (um) martelo, todos com resquícios do entorpecente.

Segundo a denúncia, "em decorrência de informações anônimas e de investigações policiais, havia indícios de que a denunciada possuía grande quantidade de entorpecentes em sua residência. Portanto, policiais civis realizaram uma campanha nas proximidades do imóvel. Certa hora, a denunciada e a testemunha Alexandra chegaram à residência. Imediatamente, os agentes se aproximaram e questionou a denunciada sobre a existência de entorpecentes no local, o que ela negou. Ato contínuo foi franqueada a entrada dos policiais na residência, que, então passaram a realizar buscas no local, até que encontraram, enrolados em um cobertor, três tabletes de maconha, os quais estavam prensados, além de uma balança de precisão,

um martelo e uma faca, todos com vestígios da droga. Novamente indagada, a denunciada confessou que guardava as drogas e os petrechos para um terceiro, mas afirmou que não comercializava os entorpecentes. Observou ter recebido a quantia de trezentos reais para guardas as drogas e os petrechos. Diante do contexto fático, a denunciada foi presa em flagrante pelos agentes de segurança pública. Na presença da autoridade policial confirmou a versão apresentada informalmente".

Antecedentes criminais às fls. 45-46 e F.A. às fls. 126-129.

Autorização da acusada para o ingresso dos policiais à fl. 37.

Certidões de antecedente à fl. 43 e F.A. às fls. 109-110.

Flagrante formalmente em ordem e presentes os requisitos do artigo 312, CPP, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva às fls. 65/66.

Após determinação do E. STJ foi realizada audiência de custódia, em que foi concedida liberdade provisória à acusada, mediante cumprimento de cautelares diversas da prisão (fls. 124/126) e alvará de soltura (fls. 138/141).

Decisão recebendo a denúncia em 12 de julho de 2022 às fls. 186.

Citada, a ré apresentou resposta à acusação às fls. 142/151.

Designada a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas, bem com, ao final, a ré foi interrogada.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a condenação da ré com o reconhecimento do tráfico privilegiado e a expedição de ofício para a Corregedoria Seccional de Botucatu para apurar a responsabilidade pela juntada do documento da fl. 37 e a conduta do delegado de polícia subscritor do interrogatório da acusada, com inserção de nome de advogado sem que estivesse presente (fls. 256-263).

Por sua vez, a Defesa Técnica requereu o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar e a nulidade da prova em virtude do ilícito praticado pelos agentes policiais. No mérito, pugnou pela absolvição da ré diante da insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso V ou VI, do CPP. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da confissão espontânea, do arrependimento eficaz e do tráfico privilegiado. Rogou pela fixação do regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição por pena restritiva de direitos em prestação de serviços à comunidade.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da preliminar da ilicitude da busca domiciliar e da contaminação das provas colhidas

A teor do art. 5º, XI, da CF/88, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

Da interpretação do referido dispositivo constitucional decorre que o ingresso no domicílio da ré seria admitido nas seguintes situações:

I) Se houvesse autorização judicial para tanto; ou

II) Se houvesse consentimento válido e inequívoco do morador; ou

III) Se houvesse fundadas razões concretas da ocorrência de flagrante delito no local.

Passo a analisar as hipóteses acima, à luz do caso concreto, tendo em vista a alegação da defesa técnica de que as provas constantes dos autos foram obtidas mediante ingresso ilegal no domicílio da acusada.

A) Da autorização judicial

A ausência de autorização judicial de busca domiciliar expedido em face da acusada é incontroversa.

B) Do consentimento válido e inequívoco do morador

O tema do consentimento do morador é ainda incipiente na doutrina e na jurisprudência pátrias, especialmente em razão da falta de especificação legal dos requisitos de sua validade.

Um dos poucos a escrever a respeito no Brasil, Pierpaolo Cruz Bottini, em artigo publicado no site Conjur, assim discorre:

"Como pontua a doutrina processual penal, durante o dia ou à noite, o morador pode

permitir a entrada em sua casa e, nessa situação, dispensa-se mandado judicial para realização de busca domiciliar. O consentimento, porém, deve ser real e livre, despojado de vícios como o erro, violência ou intimidação.

(...)

O TJ-RS recentemente destacou a invalidade do consentimento de pessoa investigada por tráfico de drogas. Na ocasião, o desembargador relator pontuou: “Não existe previsão legal para a busca domiciliar a partir da permissão informal do proprietário. Do consentimento a que se refere o artigo 5º, XI, da Constituição Federal não se infere que poderão ser realizadas buscas sem determinação judicial, apenas sob a anuência do morador. Se assim fosse, veríamos-nos diante de um quadro temerário, no qual os mandados de busca e apreensão seriam dispensáveis, já que polícia sempre poderia conseguir, extrajudicialmente, o 'consentimento' do proprietário. Afinal, é de se ter em conta que, nas circunstâncias descritas nos autos esse aval foi dado sob constrangimento” (Ap 70058172628, relator desembargador Diógenes V. Hassan Ribeiro, 3ª Câmara Criminal, DJ 24.06.2014). Sobre a forma do consentimento, deve ser expresso e jamais presumido, sendo que não há previsão legal de forma especial. Relevante destacar doutrina portuguesa que pontua a necessidade de documentação do consentimento, por qualquer forma, mesmo gravada: “Relativamente à forma do consentimento, parece-nos resultar da lei que o mesmo não pode ser dado de forma tácita, nem por via de presunção. A exigência de consentimento expresso pode retirar-se da circunstância de a lei impor obrigatoriamente a documentação do mesmo. (...). Já no que respeita à forma de documentação do consentimento, o Acórdão da Relação de Lisboa de 13 de Janeiro de 2000 veio pronunciar-se no sentido de que a lei processual penal não exige forma especial (pode ser verbal), bastando que o mesmo seja prestado anteriormente à busca e fique, de qualquer forma, documentado. A documentação do consentimento verbal pode ser efetuada, por exemplo, através de gravação sonora”.([5])

(...)

No tocante à pessoa que consente, deve ser aquele titular do direito à inviolabilidade do domicílio. A doutrina destaca que a permissão deve ser do próprio sujeito da medida de busca e apreensão ou de outra pessoa que possa, legitimamente, representá-lo. Ressalvas são feitas, ainda, às habitações coletivas, em que o consentimento por um dos moradores não autoriza a busca na casa ou aposento de terceiros.([6])

No entanto, maior relevo tem a questão do grau de esclarecimento do morador que consentiu na realização da busca e apreensão. Para que se solucione o conflito de interesses – busca da verdade para realização da justiça e inviolabilidade do domicílio – por via consensual, é necessário que aquele que consente tenha pleno conhecimento das circunstâncias e consequências da realização da busca domiciliar, bem como que isso seja documentado.

No ponto, não há previsão legal. Contudo, tratando-se de medida que pode implicar a produção de prova contra o próprio morador que consente com a busca, para que ele decida de forma justa e válida se franqueará a entrada em sua residência, necessário que no mínimo lhe sejam esclarecidos seus direitos e o alcance da inviolabilidade do domicílio, bem como as consequências da realização da busca domiciliar. A mesma lógica e o mesmo cuidado são observados nos procedimentos de interrogatórios, tanto judicial quanto policial, a fim de garantir o direito da pessoa de não produzir prova contra si (deriva das previsões constitucionais – artigo 5º, LVII e LXII – e consagrado do Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8º).

Nesse aspecto, surpreendem a doutrina e a jurisprudência espanhola, já sensibilizadas com a questão, ao sustentarem que o consentimento deve ser prestado em circunstâncias que garantam uma decisão consciente e ponderada pelo morador. Defendem, em resumo: “a) que o consentimento deve produzir-se em condições de serenidade e liberdade ambiental necessárias para autorizar a invasão de um direito fundamental como a inviolabilidade de domicílio; b) que, atendendo ao caráter fundamental do direito tutelado, a diligência se inicie com a informação do visado sobre o alcance do direito à inviolabilidade do domicílio e de seus limites, e com uma pergunta clara e concisa sobre se o visado tolera ou não a intromissão; c) a

presença de um 'letrado', para garantir a autenticidade da manifestação de vontade, evitando perguntas capciosas ou sugestivas, bem como qualquer forma de coação ou ameaça; d) que entre a solicitação do consentimento e a resposta, por parte do visado, medeie um pedido de tempo suficiente para este meditar com calma sobre o assunto e compreenda o significado e alcance da sua resposta".([7]) (...)"

No Superior Tribunal de Justiça, o tema já foi trazido de passagem em alguns julgados:

"Por fim, merece destaque a afirmação constante dos autos de que, ao se dirigirem para a residência, os policiais tiveram a entrada franqueada pela proprietária do imóvel (fls. 3 e 256). Tal realidade, a meu ver, demonstra muito mais uma situação aguda, uma vontade externada sob domínio de intensa pressão, do que uma pouco crível colaboração para que, voluntariamente, fosse autorizado o ingresso de agentes policiais em sua residência para a busca domiciliar. (...)" (Da busca e apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 133-134)." (trecho do voto do Ministro Rogério Schietti por ocasião do julgamento do RESP Nº 1.690.854 - RJ).

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PROTEÇÃO DO DOMICÍLIO (ART. 5º, XI, DA CF). ATUAÇÃO DE POLICIAIS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE. ILICITUDE DA PROVA. ENTRADA NO DOMICÍLIO FRANQUEADA PELA TIA DO PACIENTE, DIANTE DA ADVERTÊNCIA DE MONITORAMENTO POLICIAL PRÉVIO. INDIFERENÇA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. (...) 4. No caso, embora a tia do paciente tenha franqueado a entrada dos policiais no imóvel da família, diante da advertência de monitoramento estatal prévio, a "autorização" não torna lícito o procedimento policial que, diante de denúncia anônima, não procedeu investigação preliminar para confirmar, ou não, os elementos de suspeita de autoria e de materialidade delitiva. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para declarar a nulidade da prova, restabelecendo a sentença absolutória.

(...) No ponto, registro que a denúncia anônima não foi minimamente esclarecida nos autos pelos agentes públicos policiais e a suposta autorização para ingresso no imóvel, embora confirmada pela tia do réu, não é válida, tampouco concede licitude à ação policial, pois se trata de pessoa com desconhecimento da lei, desassistida de profissional da área jurídica, hipossuficiente frente ao aparato policial (DENARC) que, por si só, exerce coação com a mera presença e, portanto, compreensível que a tia do réu tenha lhes autorizado a entrada no imóvel sem o conhecimento acerca da inviolabilidade do domicílio que lhe assiste na condição de residente." (STJ - HC: 423653 RS 2017/0288292-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2018).

No julgamento do RESp 1.558.004-RS, em 22.08.2017, o Ministro Rogério Schietti avançou um pouco mais sobre a questão dos requisitos de validade do consentimento: "Sobre o específico tema do consentimento do interessado, o Tribunal Supremo espanhol decidiu, por mais de uma vez (SSTS. 1803/2002, 261/2006 e 951/2007), sobre a necessidade do preenchimento de requisitos para que a manifestação da vontade seja considerada válida, desprovida de pressão psicológica que a impeça de exercer seus direitos constitucionais, notadamente o previsto no art. 18.2 da Constituição da Espanha. Esse consentimento, "verdadera fuente de legitimación del acto de injerencia de los poderes públicos en el domicilio del imputado", decorre do próprio enunciado constitucional, como também do art. 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do art. 8 da Convenção de Roma e do art. 17 do Pacto Internacional de Direitos Cíveis e Políticos. Segundo a Corte espanhola, são os seguintes os requisitos a serem considerados para analisar o consentimento autorizado de ingresso no domicílio: a) Outorga por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus direitos; b) Outorga consciente e livre, a qual requer: b1) que não esteja invalidada por erro, violência ou intimidação de qualquer modo; b2) que não seja condicionada a alguma circunstância periférica, como promessas de qualquer atuação policial; b3) que se o consentimento for de pessoa que estiver presa/conduzida, não pode validamente prestar o consentimento se não tiver antes

a assistência de um defensor, do que constará da diligência policial (STS 2-12-1998). Isso porque se a assistência de defensor é necessária para que o conduzido preste declarações, dado o prejuízo aos seus direitos, o consentimento também o será, dada a "intimidação ambiental" ou "a coação que a presença dos agentes da atividade representa" (STS. 831/2000); c) Pode ser prestada oral ou por escrito, porém sempre vertida documentalmente; d) Deve ser outorgada expressamente, não servindo o silêncio como consentimento tácito, em face do princípio in dubio pro liberdade (SS. 7.3 y 18.12.97 e S. 23.1.98). Sobre este item, refere o Tribunal Supremo que, embora autorizado o consentimento presumido pelo art. 551 do CPP espanhol, esse dispositivo "ha de interpretarse restrictivamente, pues el consentimiento tácito ha de constar de modo inequívoco mediante actos propios tanto de no oposición cuanto, y sobre todo, de colaboración, pues la duda sobre el consentimiento presunto hay que resolverla en favor de la no autorización, en virtud del principio in dubio libertas y el criterio declarado por el Tribunal Constitucional de interpretar siempre las normas en el sentido mas favorable a los derechos fundamentales de la persona, en este caso del titular de la morada" (STS 4761/2013); e) Deve ser outorgado pelo titular do domicílio. A relação jurídica entre o titular do direito e sua salvaguarda deve prevalecer, não sendo necessária a propriedade. Em caso de várias pessoas terem seu domicílio no mesmo lugar, não é necessário o consentimento de todos, bastando a anuência de um dos cotitulares, desde que não tenha interesses contrapostos (STS. 779/2006); f) O consentimento deve ser outorgado para um caso concreto, sem que seja usado para fins distintos, ou seja, vigora a especialidade da busca (STS, sentença de 6 de junho de 2001); g) São dispensadas as formalidades exigidas no art. 569 da Ley de Enjuiciamiento Criminal (CPP da Espanha). Esses requisitos, evidentemente, não têm sido nem sequer ventilados pela jurisprudência pátria, muito menos por leis de nosso país ou, ainda, por regramentos administrativos, mas refletem uma orientação que poderia ser adotada, na medida do possível, com vistas a minimizar a praxe, tão comum em comunidades de baixa renda, em que casas são ocasionalmente invadidas sem o amparo do Direito. Nesse sentido, aliás, caracterizou-se a intervenção do Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do RE n. 603.616/TO, em raciocínio paralelo ao que levou à edição da Súmula Vinculante n. 11, da qual se extrai a necessidade de documentar, por escrito, as razões que justificaram o uso de algemas em pessoa presa. É dizer, se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa – ostentando, portanto, verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua detenção –, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal medida acautelatória, seria de demandar-se, em juízo de proporcionalidade, a legitimidade de igual providência para a invasão de um domicílio, quando, a priori, tem-se apenas a suspeita da ocorrência de um crime. (...)." (STJ - REsp: 1558004 RS 2015/0249614-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017).

Mais recentemente, em paradigmático voto no julgamento do Habeas Corpus nº 598.051 SP, em 02.03.2021, o Ministro Rogério Schietti enfrentou com profundidade o problema, propondo como conclusão do julgado neste ponto que:

"3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.

4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo."

Tal entendimento, até então da 6ª Turma da Corte, foi acompanhado pela 5ª Turma em 30.03.2021, em julgado de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas. Segue o trecho da ementa relativo ao consentimento do morador:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO NEGADA PELA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. PROVA ILÍCITA. NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA

HC 598.051/SP. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DEPENDE DE PROVA ESCRITA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL. WRIT NÃO CONHECIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...) 3. Em recente julgamento no HC 598.051/SP, a Sexta Turma, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti - amparado em julgados estrangeiros -, decidiu que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. 4. O eminente Relator entendeu ser imprescindível ao Judiciário, na falta de norma específica sobre o tema, proteger, contra o possível arbítrio de agentes estatais, o cidadão, sobretudo aquele morador das periferias dos grandes centros urbanos, onde rotineiramente há notícias de violação a direitos fundamentais. 5. Na hipótese em apreço, consta que o paciente e a corré, em razão de uma denúncia anônima de tráfico de drogas, foram abordados em via pública e submetidos a revista pessoal, não tendo sido nada encontrado com eles. Na sequência, foram conduzidos à residência do paciente, que teria franqueado a entrada dos policiais no imóvel. Todavia, a defesa afirma que não houve consentimento do morador e, na verdade, ele e sua namorada foram levados à força, algemados e sob coação, para dentro da casa, onde foram recolhidos os entorpecentes (110g de cocaína e 43g de maconha). 6. Como destacado no acórdão paradigma, "Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas - avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência cotidiana do que ocorre nos centros urbanos - ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (in dubio libertas). Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador." 7. Na falta de comprovação de que o consentimento do morador foi voluntário e livre de qualquer coação e intimidação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). (...)" (STJ - HC: 616584 RS 2020/0257456-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021).

No caso em análise, não foi demonstrado inequivocamente que o consentimento ocorreu de forma voluntária e livre, conforme se infere do relato da ré em seu interrogatório, pois restou claro que o documento com o registro escrito franqueando a entrada dos policiais (fl. 37), ainda que assinado pela ré, não está devidamente preenchido, sendo certo que os depoimentos da acusada e das testemunhas de defesa, somados às informações vagas apresentadas pelos policiais civis em juízo, indicam que o documento foi apresentado para assinatura quando a ré já estava na delegacia de polícia.

A versão apresentada pela vítima de que foi induzida em erro pelo policial Marcelo (Bola) foi amparada pela testemunha presencial Alexandra, que confirmou que os agentes disseram à acusada que sua residência estava sendo roubada para poderem ter acesso ao local e, assim, apreender as drogas, tudo a evidenciar a inexistência de consentimento consciente e voluntário da acusada para que os policiais ingressassem na sua residência.

Ademais, não se pode desconsiderar que a abordagem realizada pelos policiais implica circunstância ambiental e situacional, ainda que indireta, de intensa pressão sobre a pessoa abordada, sobretudo em detrimento daqueles que são desconhecedores de seus direitos mínimos.

É dizer que aqueles que desconhecem profundamente suas garantias mínimas se sentem intimidados diante de interpelação policial, sendo que por vezes concedem permissão para a prática de atos pelos agentes do Estado, aos quais não estão obrigados a se submeter, mas o fazem por receio do que pode advir de sua negativa, e não por livre e consciente manifestação de vontade.

Não se cuida aqui de desmerecer a valorosa e honrosa atividade policial ou de presumir a prática de coações por parte dos policiais. De forma alguma. O que se pondera, todavia, é o medo que os cidadãos em geral possuem de contrariar as autoridades estatais por conta do desconhecimento do que é ou não lícito e ao que estão ou não obrigados, circunstância esta que influencia na validade do

consentimento.

Demonstrando concretamente esse medo, a pesquisa ICJBrasil aferiu em 2016 que 56% dos brasileiros “concordam que se deve fazer qualquer coisa que um policial pede, mesmo quando se discorde da requisição” (CUNHA, Luciana Gross et al. Relatório com os dados da pesquisa Índice de Confiança na Justiça (ICJBrasil) referente ao 1o semestre de 2016. São Paulo: Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 2016, p. 18. Disponível em:).

Portanto, não se pode concluir, no presente caso, que houve consentimento livre e informado por parte da acusada, eis que (i) o documento da fl. 37 não foi devidamente preenchido, (ii) as informações constantes dos autos (depoimentos da acusada e testemunhas Alexandra e Juliana) evidenciam que o referido documento não foi apresentado antes do ingresso dos policiais, (iii) o conteúdo da ligação do policial Marcelo (Bola) para a acusada não restou esclarecido pelo agente, que se mostrou evasivo e reticente em seu depoimento, devendo, portanto, prevalecer a versão da acusada de que foi ludibriada para consentir com o ingresso dos policiais porque acreditava que sua residência havia sido invadida por terceira pessoa.

C) Das fundadas razões concretas da ocorrência de flagrante delito no local.

No que diz respeito às fundadas razões para a ocorrência de flagrante delito no local, cumpre registrar o que segue.

A questão relativa às buscas domiciliares sem mandado foi objeto de tese de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 603.616, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Na tese firmada ficou assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Atualmente, é absolutamente pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que denúncias anônimas, antecedentes no tráfico, e fuga do suspeito ao perceber a aproximação da viatura não são suficientes para o ingresso no domicílio.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA OBTIDA E DAQUELAS DELA DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protraí-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorra situação de flagrante delito. 2. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida. 3. A prova obtida com violação à norma constitucional é imprestável a legitimar os atos dela derivados. 4. Recurso especial provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de violação de domicílio e dela derivadas, por conseguinte, absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, II, do CPP. (REsp 1871856/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) (destacou-se). (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui jurisprudência no sentido de que “A existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si só, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial” (RHC 89.853-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020 – grifo nosso).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. “Os policiais militares esclareceram sob o crivo do contraditório, em detalhes e demonstrando segurança, como se deu a diligência, relataram que visualizaram o indivíduo, que percebendo a presença dos policiais tentou fugiu,

entrando em uma casa, o que motivou a suspeita por parte da equipe de rota. Disse que o réu foi abordado e nada de ilícito foi encontrado com ele. Questionaram o réu se a residência era dele, para o que obteve resposta afirmativa, bem como questionou sobre a existência de substância ilícita no interior da casa e, novamente, obteve resposta afirmativa. Relatou que o réu indicou uma cômoda no quarto onde foi localizada a droga, maconha disposta em aproximadamente 200 (duzentas) porções prontas para comercialização. Em entrevista o réu contou que guardava a droga para terceira pessoa, que desconhecia o nome, não tendo maiores informações." (Acórdão de origem, denegatório da ordem.) 2. Consoante precedente desta Corte Superior, "As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021.) 3. Do contexto fático delineado no acórdão impugnado, não se verifica a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente, ao ingresso em domicílio, sem mandado judicial, a mera suspeita da prática de tráfico de drogas, por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado fugir e entrando em uma casa. Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente. 4. Concessão da ordem de habeas corpus. Reconhecimento da nulidade das provas obtidas nas buscas ilícitas ocorridas na residência em que se encontrava o paciente. Absolvição (art. 386, II - CPP)." (HC 635.014/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 41G (QUARENTA E UM GRAMAS) DE COCAÍNA E 129G (CENTO E VINTE E NOVE GRAMAS) DE MACONHA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM ATITUDE SUSPEITA DO ACUSADO. FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte, nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas - 41g (quarenta e um gramas) de cocaína e 129g (cento e vinte e nove gramas) de maconha -, quando apoiado no comportamento suspeito do acusado, que empreendeu fuga ao ver a viatura policial, não traz contexto fático que justifica a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial, como no caso dos autos. 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 1784518/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

Por decorrência lógica da ilicitude do elemento informativo obtido por confissão informal da própria acusada no momento da abordagem na sua residência e em sede policial, conforme a fundamentação do primeiro tópico, também não é considerado lícito o ingresso em domicílio que dela decorreu.

Cito, a título de ilustração, o julgado a seguir, referindo-se, porém, ao delito de tráfico e não ao de porte para consumo pessoal, que é de menor gravidade e ao qual poderia ser aplicada a mesma razão de decidir:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INGRESSO FORÇADO NA RESIDÊNCIA A PARTIR DE DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, estava configurada a ilegalidade flagrante que autoriza a excepcional cognição de ofício da matéria posta nestes autos. 2. A sabida permanência do delito de tráfico de drogas ilícitas, cuja execução se protraí no tempo, não torna justo o ingresso forçado no domicílio fora das hipóteses registradas no art. 5º, XI, da CF/88: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para

prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 3. Neste caso, a moldura fática extraída dos autos não permitem que se conclua pela presença de elementos de suporte suficientes para justificar a decisão de ingressar na residência do paciente. Não é possível extrair quais os motivos que levaram os policiais a decidirem entrar na casa do agravado. A confissão informal, feita durante a abordagem, em situação claramente desfavorável, não é suficiente para justificar a decisão de se ingressar no imóvel e promover uma operação de busca por entorpecentes. 4. O fato de o acusado empreender fuga ao avistar a viatura da Polícia ou comportar-se de "modo suspeito" não é suficiente para justificar a decisão de ingressar na casa do investigado e proceder a busca domiciliar ou pessoal. 5. Agravamento regimental improvido." (AgRg no HC 681.198/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021). Em suma, se não há autorização judicial para ingresso em domicílio alheio, são exigidas fundadas razões da ocorrência de flagrante delito que imponha atuação policial imediata, justificadas a posteriori. Tais elementos não estão presentes no caso, pois as fundadas razões estavam amparadas, ao que se sabe nestes autos, apenas que os policiais tinham informações de que a ré guardava drogas para um traficante na comarca, e que as informações sobre a droga vieram de informações e investigações realizadas pela inteligência da polícia.

No caso dos autos, os policiais civis alegaram que tinham informações de que a ré guardava drogas para um traficante na comarca e que as informações sobre a droga vieram de investigações realizadas pela inteligência da polícia.

A ré, por sua vez, declarou que recebeu uma ligação do policial civil Marcelo (Bola) dizendo que um indivíduo havia pulado em seu quintal. Preocupada que o suposto indivíduo pudesse invadir sua residência, foi para casa junto com a testemunha Alexandra, para quem prestava serviços fazendo faxinas.

Ao chegar em sua residência, a acusada se deparou com os policiais civis, que ingressaram no local usando a justificativa de que um suposto indivíduo estaria dentro do imóvel ou subtraído algum objeto, momento em que ingressaram em um dos quartos da residência da ré e encontraram as drogas que lá estava armazenadas.

A testemunha de defesa Alexandra, presente durante a abordagem, corroborou com o depoimento da acusada e informou que em momento algum a ré foi informada pelos policiais sobre a suspeita de que havia drogas em sua residência e este era o motivo pelo qual os agentes pediram para ingressar no local.

O policial Rogério declarou que seu colega Marcelo é quem sabia das denúncias e que Marcelo fez a ligação à acusada, mas não soube dizer o teor da conversa. Aliado a isso, o policial civil Marcelo confirmou que conversou com diversos vizinhos da ré e que conseguiu com eles o número de telefone da acusada.

O policial Marcelo também confirmou ter ligado para a acusada, porém não se recorda do teor da conversa, em que pese afirmar que logo após a ligação a ré voltou para sua residência.

Ademais, o policial Marcelo, responsável pelo setor de inteligência, apenas fez menção a vagas investigações não documentadas e informou que vizinhos da acusada teriam relatado a suspeita de que ela armazenava drogas em sua residência. Contudo, o referido policial não quis informar os nomes dos vizinhos que teriam feito a denúncia, alegando querer preservá-los, bem como apresentou depoimento evasivo e, por vezes, desconexo com a realidade, não sendo possível, portanto, considerá-lo como meio idôneo de provas.

A testemunha de defesa Juliana Tofoli Machado, única vizinha da acusada ouvida em juízo, disse que mora muito próximo à casa da ré e que presenciou a ação policial desde o início até o final. Relatou que haviam três viaturas, onde estavam os policiais Vô, Bola e Guiari e que os policiais queriam saber onde estava a ré, mas não diziam o porquê. Asseverou que os vizinhos não suspeitavam que a ré guardava drogas e que para a depoente foi uma grande surpresa. Alegou que viu a ré chegando e os policiais pediram para conversar com a ré dentro da residência e que a ré morava sozinha no local, bem como não havia movimentação estranha de pessoas, pois apenas os familiares da ré a visitavam. Viu os policiais falando com os vizinhos e que dona Antônia estava passando por problemas de saúde.

Assim, em que pese a efetiva apreensão das drogas, não foram demonstradas as

fundadas razões para o ingresso forçado dos policiais na residência da acusada, uma vez que (i) não há qualquer investigação documentada acostada aos autos, (ii) a única vizinha ouvida em juízo negou qualquer suspeita de que a acusada armazenava drogas em sua residência (fato que afasta a alegação do policial Marcelo) e (iii) o investigador Marcelo se negou a esclarecer com precisão como teve conhecimento de que as drogas estavam na residência da acusada, já que a versão de que os vizinhos o procuraram para informar que suspeitavam que a ré estava traficando foi desmentida pela testemunha Juliana.

À luz desses parâmetros, e pelo contexto fático ora delineado, não se pode admitir a existência de elementos concretos que justificassem a invasão de domicílio sem prévia autorização judicial, por se tratar de tema que já está sob o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Essas são as razões pelas quais, dado que a casa é asilo inviolável do indivíduo, desautorizado estava o ingresso na residência da ré, de maneira que as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram (por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada – artigo 157, §1º, Código de Processo Penal).

Impositiva, portanto, a absolvição da acusada, por ausência de provas acerca da materialidade do delito do artigo 33, "caput", da Lei de Drogas.

Anoto, por fim, que, no atual estado civilizatório do Estado Democrático de Direito, a atividade estatal encontra-se balizada por regras de atuação que devem ser obedecidas. Se a Constituição exige requisitos para o ingresso no domicílio é porque entende que a intimidade e a privacidade dos indivíduos são valores fundamentais a serem preservados (art. 5º, X e XI, CF), o que se deve garantir em prol de todos as pessoas, sem exceção.

ISSO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial para ABSOLVER A RÉ ANTÔNIA FAVERO da imputação da conduta típica descrita no topo do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

Defiro o pedido formulado pela Douta Promotora de Justiça à fl. 263, devendo ser oficiado, com urgência, à Corregedoria de Polícia Civil Seccional de Botucatu, com cópias das mídias contendo os depoimentos colhidos nas audiências realizadas nestes autos para pronta apuração das seguintes responsabilidades:

(i) juntada do documento da fl. 37 sem o devido preenchimento;
(ii) conduta temerária dos policiais que ligaram para acusada e falsearam a existência de um assalto para ingressar de forma ilícita da residência; e
(iii) apuração da conduta do Delegado de Polícia subscritor do documento relativo ao interrogatório policial da acusada (fls. 16-17), eis que houve inserção do nome de advogado (Dr. Franscico Moscatelli Neto) sem a efetiva presença do referido profissional, que sequer foi constituído pela acusada, conforme depoimento prestado pelo próprio causídico como testemunha compromissada.

Considerando que este Juízo exerce função de Corregedor da Polícia Civil da Comarca de São Manuel, o resultado das apurações deverão ser encaminhados para conhecimento tão logo ultimado eventual procedimento administrativo, devendo a Z. Serventia, em caso de inércia do Órgão Correicional, cobrar informações sobre o expediente em 90 dias contados do recebimento do ofício, reiterando-se a providência a cada 90 dias até o efetivo cumprimento.

Cópia da presente, assinada digitalmente, servirá como mandado/cartaprecatória/alvará/ofício/termo para as finalidades cabíveis, lembrando-se que a sua autenticidade poderá ser confirmada no endereço eletrônico do E. TJSP (www.tjsp.jus.br).

Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Expeça-se o necessário.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

São Manuel, 22 de novembro de 2022.

JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA